

Indications pour la fiche d'arrêt, Extraits tirés de M.-A. Frison-Roche, Introduction générale au droit, Dalloz, 3ème éd

Il s'agit de procéder de manière systématique à l'analyse d'une décision de jurisprudence. La fiche d'arrêt est, normalement, le préalable de tout commentaire d'arrêt. Mais, en tant que telle, la rédaction d'une fiche d'arrêt constitue un exercice en soi, propre à être ultérieurement utilisée dans le cadre d'un commentaire d'arrêt. Plus généralement, à l'occasion de toute investigation jurisprudentielle, y compris dans la perspective de préparation d'un mémoire, d'un rapport de recherche ou encore d'une thèse, il est souvent nécessaire d'analyser méthodiquement des décisions judiciaires.

Exercice propre au droit, l'analyse de décisions judiciaires- jugements de tribunaux ou arrêts de cours d'appel ou de la Cour de cassation, mais ici on emploie volontiers large de « fiche d'arrêt »- comporte certaines exigences auxquelles il convient de se soumettre dès la première année des études de droit. En effet, avant de vous essayer au commentaire d'arrêt, il convient de savoir procéder à la présentation analytique de l'arrêt.

Cela implique son « démontage », disons encore sa décomposition, bref la distinction méthodique de ses composantes. Quelles composantes ? Les voici :

1. Faits

Il s'agit de relever, d'une façon objective, avec l'œil d'un observateur extérieur, dans l'ordre chronologique, tous les faits qui ont donné naissance au litige – disons encore présidé à sa genèse-. Il ne faut pas omettre les dates, qui peuvent être précieuses. Vous ne devez pas négliger l'importance des faits, qui ont souvent conditionné la solution juridique imposée par la décision. C'est le souci de respecter et de considérer les faits qui permet ensuite de prendre de la hauteur de vue, dans une perspective juridique.

2. Procédure

Il s'agit de retracer « l'histoire judiciaire » de l'affaire. On considère qu'elle commence au moment où l'un des acteurs saisit le juge. Vous devez mentionner qui est demandeur et qui est défendeur à l'instance. Vous devez préciser ce qu'ils demandaient à la juridiction (par exemple, la nullité d'un contrat ou la condamnation du défendeur à des dommages et intérêts). Attention, si le défendeur est condamné en première instance, il peut être l'appelant et le demandeur à l'instance être l'intimé devant la Cour d'appel. Vous devez mentionner les différentes juridictions saisies, la date des décisions et en faveur de qui il a été statué. Vous devez faire attention à bien respecter le vocabulaire de la procédure. Ainsi, un simple tribunal rend un « jugement », tandis qu'une cour rend un « arrêt » et le Conseil constitutionnel une « décision ». On « interjette appel » mais on « forme un pourvoi » devant la Cour de cassation. Des inexactitudes à ce sujet sont notablement sanctionnées lors de l'examen.

3. Prétentions des parties

Leur analyse est très importante. L'expression consacrée de « prétentions des parties » n'est d'ailleurs pas satisfaisante car l'étude ne se limite pas aux argumentations développées par les parties à l'instance, mais porte aussi sur les raisonnements adoptés par les juges du fond. Il s'agit en effet plus précisément de démontrer les raisonnements qui ont été soutenus par les différents acteurs au procès, jusqu'à ce que statue la juridiction dont vous commentez l'arrêt. Cette analyse exclut donc le propre raisonnement de la Cour dont vous commentez l'arrêt.

Il est très important de ne pas mélanger les différents « discours » et de ne pas confondre, par exemple, ce que soutient le pourvoi en cassation et ce que va énoncer l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Il faut donc, à ce stade, faire preuve de beaucoup de minutie pour, d'une part, éviter les contresens et, d'autre part, dégager les différents éléments sur lesquels le commentaire éventuel pourra porter ultérieurement. Vous devez rappeler à cette occasion ce que désire obtenir le demandeur et préciser quels textes il invoque à l'appui de sa prétention. Sur ce texte, la partie bâtit un raisonnement qui vise à interpréter le

texte dans un sens qui lui est favorable. C'est ce raisonnement que vous devez exposer point par point. Vous ferez de même au sujet de la prétention du défendeur. La difficulté tient à ce que parfois le raisonnement n'apparaît pas ou n'est reproduit que d'une façon elliptique dans la décision que vous analysez. Vous devez à ce moment vous aider de vos connaissances et de votre sens de la logique juridique. Cette même démarche, vous devez l'appliquer au raisonnement qu'ont retenu les différentes juridictions saisies, si ce raisonnement apparaît dans l'arrêt ou si vous pouvez le reconstituer. Si c'est un arrêt de la Cour de cassation dont on vous demande l'analyse, vous devez terminer cette phrase par l'exposé minutieux du raisonnement soutenu par le pourvoi en cassation, tendant à obtenir la cassation de la décision attaquée.

4. Question de droit

La formulation de cette « question de droit » est indispensable, en ce qu'elle atteste de votre bonne compréhension de ce qui est essentiel dans la décision et en ce que, dans un stade ultérieur, elle fournit l'armature d'un éventuel commentaire.

La question de droit résulte de la confrontation entre les différentes thèses soutenues par les parties, à propos d'une difficulté juridique. Lorsqu'il s'agit d'analyser un arrêt d'appel, on confrontera plus usuellement la position adoptée par les juges de première instance avec celle soutenue par la partie appelante. Lorsqu'il s'agit d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, on confrontera la décision de la Cour d'appel avec la thèse avancée par le pourvoi. Vous remarquerez que la question de droit peut découler d'une comparaison entre ce qui a été décidé et sa critique, mais aussi d'une comparaison entre les différentes motivations qui justifient soit la décision, soit sa critique. C'est alors l'observation de la contradiction entre deux raisonnements qui permet de dégager la difficulté juridique. En résumé, à partir d'une situation de fait, on induit la question qui se pose en termes de droit. De la réponse à cette question, on déduit la solution du litige.

L'exposé en termes abstraits de cette difficulté juridique constitue la « question de droit ». En raison de la fonction des organes juridictionnels, il est fréquent que l'analyse d'un arrêt rendu par les juges du fond, saisis du fait et du droit, conduise à poser la question de droit d'une façon qui prenne en considération des éléments concrets, tandis que l'analyse d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, qui ne juge qu'en droit, facilite la formulation de la question d'une façon plus détachée des faits. Vous serez sensible au fait que la possibilité de poser une question de droit de façon ramassée et abstraite est souvent le signe d'un arrêt de principe, tandis que la nécessité de poser une question de droit d'une façon développée et proche des faits montre que ceux-ci ont été spécialement pris en considération pour la solution retenue, ce qui est le signe d'un arrêt d'espèce.

Il peut n'y avoir qu'une question de droit ; il peut en exister plusieurs. Cela dépend de la configuration du litige, dont l'issue peut en effet dépendre de la résolution d'une seule ou de plusieurs questions. Ces différentes questions peuvent être autonomes les unes par rapport aux autres, notamment parce que le procès a été l'occasion pour les parties de formuler des prétentions diverses ; les questions peuvent aussi être liées les unes aux autres, notamment parce que la résolution de la première difficulté juridique en engendre une seconde ; il y a alors une sorte de « cascade » de questions de droit. Il convient dans ce cas de noter dans votre analyse ce lien qui existe entre les différentes questions de droit. Lorsqu'il s'agit d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, la pluralité des questions de droit apparaît souvent à travers la multiplicité des moyens formellement mis en œuvre par le pourvoi, chacun des moyens correspondant normalement à une question de droit distincte. Lorsque la décision analysée met en jeu plusieurs questions de droit, plusieurs thèmes juridiques, cela facilite la construction du plan d'un éventuel commentaire, chaque difficulté faisant l'objet de développements distincts.

5. Décision

Si vous avez, avec précision et avec la progression voulue opéré les analyses précédentes, il ne vous sera pas difficile de relever dans l'arrêt étudié la réponse que la Cour apporte à la question de droit. Cette réponse figure dans le dispositif de la décision, mais aussi dans les motifs qu'elle énonce pour justifier la solution retenue. Vous ne devez donc pas omettre de noter soigneusement le raisonnement qu'elle

utilise pour retenir cette solution plutôt qu'une autre. Vous devez mentionner le visa pour les arrêts de cassation et l'existence soit d'un attendu de principe, soit d'un chapeau intérieur.

Annexe 1 : La forme propre aux arrêts rendus par la Cour de cassation avant l'adoption du nouveau mode de rédaction des arrêts en 2019 (Sur lequel, voir document : Le mode de rédaction des arrêts change)

La Cour de cassation ne connaît pas de la situation du demandeur, ni de sa demande au fond mais uniquement de la réponse qui lui a été apportée par un juge : la Cour de cassation ne juge pas l'affaire, mais une décision rendue à son propos. En ce sens, l'objet et les moyens de la demande (appelée pourvoi) sont spécifiques.

- **L'objet du pourvoi** ne concerne pas le fond de l'affaire, mais la nullité d'une décision déjà rendue par un juge du fond. Le demandeur au pourvoi expose des critiques à l'endroit du raisonnement d'un juge du fond; il les présente sous la forme de *moyens* et il les divise par *branches*. Aussi la Cour de cassation ne connaît-elle pas de l'ensemble de la décision attaquée, mais seulement des griefs qui lui sont adressés par le pourvoi (sauf exception, ce que l'on appelle les *moyens de pur droit* ainsi que les *moyens d'ordre public*). Soit l'une des critiques présentée est fondée et la décision est cassée; soit aucun grief n'est convaincant et le pourvoi est rejeté. *Le rejet ne signifie donc pas que la décision attaquée est exempte de critique, mais que les griefs du pourvoi n'étaient pas de nature à emporter la cassation.* Il faut en retenir, et cela est essentiel, que le rejet d'un pourvoi ne signifie pas l'adhésion de la Cour de cassation au raisonnement des juges du fond.

- **Les moyens du pourvoi** sont en nombre restreint, car les faits sont exclus du débat au seul profit de la règle de droit, et parce qu'au sein des arguments juridiques (les arguments de pur droit), les cas d'ouverture à cassation sont réduits. Certains concernent la procédure (incompétence et excès de pouvoir; violation de la procédure; contrariété de décision; défaut de motivation); d'autres sont très spécifiques (perte de fondement juridique, dénaturation). Ces cas d'ouverture, s'ils sont retenus par la Cour de cassation, ne présentent que peu d'intérêt au fond du droit, puisqu'ils ne concernent pas directement une règle de droit substantiel, mais généralement une règle de procédure. Sont plus riches de sens, en ce qu'ils se rapportent à l'interprétation de la règle de droit, les hypothèses de violation de la loi et de manque de base légale.

(Voir, pour un approfondissement de cette question, M-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier et J. Buk Lament, *La technique de cassation*, Dalloz, 8^{ème} éd. 2013 ; J-F Weber, Comprendre un arrêt de la Cour de cassation en matière civile, site de la Cour de cassation, Bulletin d'information pour 2009) :

L'arrêt de rejet : Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel est rejeté.

Si la Cour de cassation n'approuve pas les motifs de la Cour d'appel, elle opère une substitution de motifs c'est à dire qu'elle substitue à un motif inexact un motif de droit qui n'avait pas été explicitement invoqué par les parties. Cet arrêt a alors la même portée normative qu'un arrêt de cassation dans la mesure où la Cour de cassation censure la motivation retenue par les juges du fond. En utilisant la formule « à bon droit » ou « légitimement », la Cour de cassation souligne l'importance de l'arrêt de rejet rendu puisqu'elle corrobore l'interprétation de la règle de droit retenue par les juges du fond. La portée normative de l'arrêt est en revanche moindre si la Cour de cassation se réfère au pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation se borne alors à vérifier que les juges du fond ont motivé leurs décisions et répondu aux conclusions.

Il se compose :

- décision de la Cour d'appel (ce qui permet de présenter les faits)
- moyen du pourvoi (éventuellement composé de plusieurs branches) on y trouve la formule « alors que »

- motivation et solution (« mais attendu que »)

Il peut y avoir plusieurs moyens.

L'arrêt de cassation : la décision attaquée est annulée

Il se compose de :

- un visa (article(s) et ou principe(s)), suivi éventuellement d'un attendu de principe,
- la solution de la Cour d'appel (ce qui permet de présenter les faits) et sa motivation
- la motivation et la solution de la Cour de cassation (« mais attendu que »)

Annexe 2 : La cassation en matière civile, par Vincent Vigneau, conseiller à la Cour de cassation, professeur associé à l'UVSQ

Une grande partie des juristes n'ont qu'une vision abstraite du fonctionnement de la Cour de cassation. S'ils possèdent pour la plupart une connaissance approfondie de sa jurisprudence, ils ignorent le plus souvent les mécanismes qui conduisent à la prise de décision et les règles d'élaboration des arrêts. Ces règles, qui n'ont pas toutes un fondement textuel et résultent souvent d'usages et de pratiques, sont rarement étudiées en faculté. Traditionnellement, le droit et la jurisprudence sont enseignés en France essentiellement dans leur aspect normatif. Les étudiants apprennent les différentes règles de droit et la façon dont elles sont interprétées par la jurisprudence. En revanche, presque aucun enseignement n'est consacré à l'étude des processus de prise de décision par les juges, si ce n'est l'apprentissage des règles de procédure. Dans les pays de Common Law au contraire, notamment aux Etats-Unis, le droit n'est pas considéré comme un phénomène autonome, isolé du reste de la société, mais un produit social, né des conflits sociaux et répondant aux besoins de la collectivité. Le phénomène juridique n'est donc pas étudié uniquement sous son aspect légal, mais en faisant aussi appel à d'autres disciplines, notamment les sciences sociales. Ainsi, l'étude du droit, destinée à permettre de prévoir les décisions du juge, comprend dans une part importante l'étude du fonctionnement des juridictions et des mécanismes qui conduisent le juge à décider.

C'est pourquoi il paraît important de présenter, de façon très concrète, l'organisation du travail au sein de la Cour de cassation et la façon dont sont élaborées, collectivement, ses arrêts.

I Le rôle de la Cour de cassation

A cet égard, et pour bien comprendre comment fonctionne la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, il faut avoir à l'esprit qu'elle remplit deux rôles à la fois distincts et complémentaires ; c'est à la fois une cour régulatrice et une instance disciplinaire.

1°/ Une cour régulatrice

Placée au sommet de la hiérarchie judiciaire, elle a d'abord pour mission d'assurer l'égalité des citoyens en imposant une interprétation uniforme de la loi.

Cette fonction la distingue de toutes les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Elle la tient tant de sa situation unique (*«Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation»* précise l'art. L 411-1 du code de l'organisation judiciaire) que du statut des magistrats qui la composent, nommés au plus haut niveau hiérarchique. Choisis majoritairement parmi les présidents des chambres des cours d'appel, ils font bénéficier la Cour de l'autorité acquise au cours d'une carrière dont la réussite est consacrée par le choix du Conseil supérieur de la magistrature.

Cet ascendant sur l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire que lui confère ce positionnement lui permet d'exercer non seulement, un véritable pouvoir normatif, para-législatif, dans les espaces d'appréciation laissés par le législateur, mais aussi, depuis l'arrêt *Sociétés Jacques Vabre* de la chambre mixte du 24 mai 1975, une autorité supra-législative par l'intermédiaire du contrôle de conventionnalité.

Hormis les cas où la loi est si claire et si précise qu'il suffit de l'appliquer, le juge doit, souvent, se livrer à un travail d'analyse du sens et de la portée de la règle abstraite pour en déduire une application concrète. Or ce travail d'interprétation peut donner lieu à des lectures différentes selon les juges.

C'est la mission première de la Cour de cassation que d'harmoniser l'interprétation de la loi de façon à ce que les citoyens soient jugés de la même façon sur l'ensemble du territoire français.

C'est pourquoi, dans un souci de clarté, les arrêts de la Cour de cassation sont rédigés non pas comme les jugements des juridictions ordinaires, qui doivent justifier leur décision, mais de façon concise, comme des textes de loi, et énoncent de façon nette et précise la règle qu'ils fixent.

L'intervention de la Cour de cassation se révèle aussi primordiale pour compléter la loi lorsqu'elle est incomplète ou l'adapter aux évolutions de la société.

Mais les décisions de la Cour qui remplissent véritablement ce rôle sont en réalité en un nombre réduit, probablement les seuls arrêts publiés dans son bulletin officiel (c'est-à-dire environ 10%), voire les arrêts cités dans son rapport annuel (environ 1%).

Pour ces quelques arrêts, la portée de décision de la Cour de cassation dépasse l'enjeu du litige qui oppose les parties. Profitant d'un pourvoi, la Cour y affirme son rôle créateur de droit, en complétant le silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi (pour reprendre les termes de l'article 4 du code civil), en interprétant un texte nouveau, en affirmant les principes nécessaires à la validité et la cohérence de notre système juridique ou en approuvant une évolution nécessaire du droit pour tenir compte des évolutions de la société.

La grande majorité des décisions rendues par la Cour de cassation correspondent en réalité à une autre fonction fondamentale: celle de vérifier que les décisions des juridictions du fond sont rendues dans le respect des règles de la procédure et ne comportent pas d'erreur de droit.

2°/ Une instance disciplinaire

Si elle remplit véritablement une fonction juridictionnelle, la Cour de cassation n'en est pas pour autant un troisième degré de juridiction. Bien que placée au sommet de la hiérarchie judiciaire, elle est, paradoxalement, celle dont les pouvoirs juridictionnels sont les plus limités.

Selon le second alinéa de l'article L 411-2 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation ne connaît pas, sauf disposition législative contraire, du fond des affaires. Son rôle consiste à apprécier la conformité des jugements en dernier ressort qui lui sont déférés aux règles de droit.

Si l'en était autrement, on déplorerait deux inconvénients majeurs :

- tenue de rejurer non seulement le droit mais aussi les faits, la Cour de cassation se verrait dans l'obligation de mener des investigations, d'entendre les témoins, d'ordonner des expertises. Elle ne disposerait dès plus du temps nécessaire pour exercer sa fonction première d'harmonisation de la règle de droit.
- les délais de traitement des affaires seraient considérablement allongés, au détriment des justiciables et la multiplication des voies de recours ordinaire inciterait les plaideurs de mauvaise foi à les exercer à des fins purement dilatoires.

Pour éviter ces travers, la Cour de cassation n'aurait pas d'autre solution que d'instaurer les mêmes règles de fonctionnement que les cours suprêmes de style Common Law, de n'examiner que les affaires qui présentent un intérêt général, c'est-à-dire devenir une autorité para-législative et ne plus être une juridiction au service de tous les justiciables: il en découlerait inévitablement une rupture d'égalité des citoyens devant la loi.

Juge de la façon dont les juges ont jugé, et non juge des affaires, la Cour de cassation intervient ainsi toujours après un autre tribunal situé en dessous d'elle dans la hiérarchie judiciaire. Contrairement au Conseil d'Etat, elle ne peut jamais être saisie en dernier ressort et n'exerce son contrôle qu'à l'occasion des pourvois qui lui sont déposées, et en fonction des moyens qui lui sont soumis par les parties.

Dépourvue du pouvoir d'appréciation des éléments de fait, elle demeure tributaire des constatations de fait des juridictions du fond qu'elle ne remet pas en cause et sur lesquels elle se fonde. C'est d'ailleurs pour cette raison que ses arrêts débutent toujours par la mention « *Attendu, selon l'arrêt attaqué, que ...* »

C'est pour les mêmes motifs que le pourvoi en cassation ne peut être considéré comme une voie de réformation. Ne pouvant pas non plus évoquer les affaires, comme le fait souvent le Conseil d'Etat, la Cour de cassation n'a le pouvoir que de confirmer ou d'infirmer les décisions rendues, et ce, dans les limites de sa saisine. Si elle estime que la loi a correctement été appliquée, elle rend un arrêt de rejet. Si, au contraire, elle considère que la loi a été violée, elle rend un arrêt de cassation qui annule la décision attaquée. Et comme elle n'a pas le pouvoir de rejurer l'affaire, la Cour de cassation ne peut, en ce dernier cas, que renvoyer l'affaire devant une autre juridiction du fond pour qu'il soit statué de nouveau en fait et en droit, dans la limite de la cassation intervenue.

Ce n'est que très exceptionnellement, lorsqu'il n'y a plus rien à juger sur le fond ou lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée, que la Cour de cassation peut statuer sans renvoi. (L'application des dispositions de l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire demeure encore marginale mais progresse. Sur les 4041 arrêts de cassation prononcés en 2007 par les cinq chambres civiles, 641 l'ont été sans renvoi, soit 15%).

En application de l'article 604 du code de procédure civile, selon lequel « *le pourvoi en cassation entend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit* », la Cour de cassation s'assure de la correcte application par les juges des textes aux situations de fait qui leur sont soumises, contrôle la qualité et la rationalité de la motivation de leurs jugements et le respect par eux des procédures.

Autrement dit, elle contribue à garantir aux citoyens un niveau de qualité supérieure des décisions juridictionnelles.

Cette mission fondamentale explique pourquoi, et contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, il n'existe aucun dispositif limitant l'accès des citoyens à la Cour de cassation.

En France, en effet, tout justiciable peut envisager d'accéder, à un moment ou à un autre de son procès, à la Haute juridiction, quelle que soit l'importance de son affaire, de ses enjeux financiers ou juridiques. Le droit de saisir le juge contient en germe celui de saisir la Cour de cassation.

Tel n'est pas le cas, par exemple dans les pays de Common Law où les justiciables ne se voient pas reconnaître l'existence d'un droit d'accès à la Cour suprême dont le rôle est uniquement de dire le droit, pas de contrôler la qualité des décisions rendues par les juges. Dans ce type de système, parfois qualifié d'*aristocratique*, par opposition au système *démocratique*, seules sont examinées par la Cour suprême les affaires que celle-ci estime devoir examiner au regard de l'intérêt juridique ou politique qu'elles présentent.

Ainsi, par exemple, la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique, qui n'examine que les cas « graves et d'importance générale », ne juge, sur les milliers de requêtes qui lui sont adressées chaque année, qu'environ 70 affaires par an.

Les requêtes qui lui sont adressées sont préalablement examinées par les assistants des juges (chaque juge de la Cour suprême en a quatre à son service, sauf le président, qui en a droit à cinq), qui en font rapport. Ces rapports sont ensuite diffusés aux membres de la Cour. Si quatre d'entre eux au moins le décident, l'affaire est jugée par la Cour suprême. A défaut, elles ne sont pas examinées.

C'est un tout autre paysage institutionnel qui s'offre en France.

3°/ Le processus de décision à la Cour de cassation

La Cour de cassation, qui ne dispose pas de cette même faculté de choisir ses affaires, traite 28 000 affaires chaque année, lesquelles ont toutes vocation à faire l'objet d'un examen par une formation juridictionnelle.

Cet examen est précédé par le dépôt d'un pourvoi, acte par lequel une partie saisit la Cour de cassation. Ce pourvoi est formé au greffe de la Cour de cassation en matière civile, à celui de la juridiction qui a rendu la décision attaquée en matière pénale. Sauf dans le cas où il l'aurait déjà fait dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur est ensuite tenu d'exposer ses moyens de cassation en déposant au greffe, dans des délais déterminés par la loi, un mémoire ampliatif.

Une fois le mémoire ampliatif déposé, le dossier est orienté vers une chambre par le service de documentation et d'études suivant la répartition ordonnée par le premier président. A cet effet, ce service procède à l'analyse du ou des moyens du pourvoi, à la recherche d'affaires connexes en cours et de précédents sur la question juridique posée par le pourvoi et à la rédaction d'un pré-tirage utilisant la nomenclature des arrêts de la Cour de cassation.

Après le dépôt du ou des mémoires en défense, ou expiration du délai de dépôt de ces mémoires, le dossier est distribué à la chambre compétente puis confié par le président de celle-ci à un conseiller ou conseiller référendaire pour qu'il l'étudie et en fasse rapport.

Les conseillers et conseillers référendaires possèdent chacun plusieurs spécialités dans les diverses matières ressortissant de la compétence de leur chambre. En général, il est fait en sorte que chaque spécialité soit partagée par au moins deux magistrats de chaque chambre, de façon à favoriser entre eux le dialogue et le partage de connaissances, et éviter qu'une matière soit « confisquée » par un seul magistrat. Ce travail conjoint facilite aussi la transmission du savoir en cas de départ de la cour de cassation.

En moyenne, chaque conseiller ou conseiller référendaire se voit confier, en tant que rapporteur, une douzaine de dossiers chaque mois. Sauf dans les hypothèses où le premier président a réduit les délais de dépôt des mémoires en application de l'article 1009 du code de procédure civile, et dans certaines matières au pénal, notamment dans les pourvois relatifs à la détention, le rapporteur n'a pas de délai fixé pour déposer son rapport.

Le rôle du rapporteur consiste d'abord à étudier le dossier dans tous ses aspects. Bien évidemment, les aspects juridiques sont privilégiés. Le rapporteur se doit d'abord d'étudier la législation applicable, la position de la jurisprudence de la Cour de cassation et l'analyse de la doctrine sur la question de droit soulevée par le pourvoi. Parfois, il peut lui être utile d'étendre ses recherches à la jurisprudence des juridictions du fond, lorsqu'il s'agit de questions nouvelles ou lorsque l'interprétation de la Cour de cassation rencontre une résistance des cours d'appel, ou de juridictions étrangères. Il n'est pas rare non plus qu'il s'intéresse à l'environnement économique et social du dossier de façon à évaluer au

mieux les conséquences concrètes de la décision à venir. S'il l'estime opportun, le conseiller rapporteur peut demander à être secondé par un membre du service de documentation et d'études pour procéder à une recherche de doctrine ou de jurisprudence. Si cet examen lui révèle l'existence d'un moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, d'une cause recevabilité ou la possibilité d'éviter la cassation par substitution de motifs, il doit en aviser les parties et les inviter à présenter leurs observations.

A l'issue de cette étude, le rapporteur rédige un rapport. Le contenu de ce rapport a été modifié depuis le 1er janvier 2002, date à partir de laquelle le bureau de la Cour de cassation a décidé, pour satisfaire aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme relative au principe de l'égalité des armes, qu'il serait communiqué aux parties et que l'avocat général n'aurait plus connaissance de l'avis du rapporteur et n'accéderait plus au délibéré.

Jusqu'à cette date, le rapport ne contenait que l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties. Désormais, il est conçu comme un exposé objectif de l'ensemble des données de l'affaire. Elément central de la procédure, soumis au principe de la contradiction, il est destiné tout à la fois à éclairer les membres de la formation de jugement et à centrer le délibéré sur les éléments déterminants, qu'à permettre à l'avocat général de mesurer rapidement l'intérêt du pourvoi et aux parties de s'assurer que le rapporteur n'a pas dénaturé leurs écritures. A cet effet le rapport comporte aussi une synthèse des moyens du pourvoi avec l'identification de la ou des difficultés de droit que peut poser le pourvoi, et qui méritent de retenir l'attention, et une discussion dans laquelle sont cités les précédents jurisprudentiels et les commentaires ou études publiés, de nature à en éclairer la solution.

Le cas échéant, le rapporteur explique en quoi le pourvoi serait irrecevable ou ne reposerait sur aucun moyen sérieux, et ainsi justifierait une non-admission.

Sauf dans cette hypothèse où le dossier est orienté vers une audience de non-admission, le rapport ne doit pas révéler l'opinion personnelle du rapporteur, laquelle est soumise au secret du délibéré.

Le rapport est rédigé sur un support informatique normalisé et enregistré sur le serveur informatique du greffe qui en assure la communication aux parties et à l'avocat général.

Si le dossier ne relève pas de la non-admission, le rapporteur rédige aussi un avis dans lequel il exprime son opinion motivée et un ou plusieurs projets d'arrêt. Lorsque la solution paraît s'imposer, il n'en rédige en général qu'un seul, avec éventuellement des variantes rédactionnelles. En revanche, lorsque la question posée est nouvelle ou que l'affaire est complexe, il est souvent conduit à rédiger plusieurs projets, à la cassation et au rejet.

Cet avis et ces projets sont soumis au secret du délibéré. Ils ne sont donc communiqués ni aux parties ni, mais ce depuis 2002 seulement, à l'avocat général. Ils seront en revanche diffusés à l'ensemble des magistrats du siège composant la formation de jugement.

A l'issue de ses travaux écrits, le conseiller rapporteur décide de l'orientation du dossier.

S'il estime que la solution, de rejet ou de cassation, s'impose, il oriente le pourvoi vers la formation ordinaire de trois magistrats, en pratique le président de chambre, le doyen et le rapporteur.

Si le pourvoi est à l'évidence irrecevable ou ne repose pas sur des moyens sérieux, il sera aussi orienté vers cette même formation qui la déclarera non-admis par une décision non motivée.

Contrairement à ce qui est parfois répandu, la procédure de non-admission n'est pas un mécanisme de filtrage des pourvois qui priverait les parties du droit d'accéder à une formation juridictionnelle. Elle n'est pas non plus un mécanisme d'examen sommaire et rapide des dossiers. La non-admission n'est décidée qu'après étude complète du dossier par le rapporteur, qui l'a examinée de la même façon que les autres dossiers et pour lequel il rédige un véritable rapport. Ce rapport est communiqué à l'avocat général et aux parties qui peuvent, le cas échéant, présenter des observations complémentaires. La non-admission ne fait donc pas gagner du temps d'étude. Elle permet en revanche d'économiser le temps de rédaction de l'arrêt, et du délibéré correspondant, dans des affaires pour lesquelles une motivation spécifique ne présenterait pas d'intérêt.

Enfin, si l'affaire pose difficulté, elle est renvoyée devant la formation de section, composée d'au moins cinq magistrats, ou encore vers la formation plénière de la chambre, une chambre mixte ou l'assemblée plénière de la Cour.

La chambre mixte juge les affaires qui relèvent de la compétence de plusieurs chambres. Le but de son intervention est d'éviter la contrariété de jurisprudence au sein de la Cour. Une chambre mixte est aussi obligatoirement saisie lorsqu'il y a partage des voix devant la chambre normalement compétente.

Elle est présidée par le Premier président et est composée du président, du conseiller-doyen et de deux conseillers d'au moins trois chambres.

L'Assemblée plénière est saisie dans deux hypothèses :

- premièrement, lorsque après un premier pourvoi, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire et qu'un second pourvoi est formé contre la décision de la juridiction de renvoi. Dans ce cas la saisine de l'Assemblée plénière est de droit.
- deuxièmement, dès le premier pourvoi, lorsque l'affaire pose une question de principe. Dans ce cas, c'est le Premier président de la Cour, le Procureur général ou la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée qui décident du renvoi devant l'Assemblée plénière.

Dans les deux cas, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de l'Assemblée plénière.

L'assemblée plénière est composée du premier président, des présidents et des doyens des six chambres ainsi que d'un conseiller par chambre spécialement désigné par le premier président, soit dix neuf membres.

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidée soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance du premier président, soit par arrêt de la chambre. Il est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Une fois les travaux préparatoires du rapporteur achevés, le dossier transmis à un avocat général qui rédige un avis communiqué aux parties, avant d'être examiné par la conférence.

Cette conférence est composée du président de la chambre, ou de la section, et du doyen de la section compétente. Deux ou trois semaines avant l'audience, elle procède à un premier examen des affaires. A cette occasion, elle formule les observations et les suggestions qui lui paraissent être de nature à faciliter le délibéré. A cet effet, elle peut être conduite à suggérer au rapporteur de modifier ses projets, d'en préparer de nouveaux ou de procéder à de nouvelles recherches. La conférence peut aussi décider de modifier l'orientation choisie initialement par le rapporteur, soit d'office, soit à la demande de l'avocat général ou d'une des parties.

L'audience débute par une partie publique au cours de laquelle le rapporteur donne connaissance de son rapport. Très rarement, les parties interviennent oralement par l'intermédiaire de leurs avocats et s'il le juge nécessaire, l'avocat général présente oralement ses observations. La partie publique de l'audience une fois achevée, le délibéré est ouvert par l'avis du rapporteur qui prend la parole en premier, suivi par le doyen puis par les autres membres de la chambre par ordre d'ancienneté à la Cour, le président s'exprimant en dernier. Sauf dans les dossiers où ils rapportent, la voix des conseillers référendaire n'est que consultative.

Comme dans tout délibéré, la décision est prise à la majorité des voix, ni celle du président, ni celle du doyen ni celle du rapporteur n'étant prédominante. Une fois la décision arrêtée, le rapporteur lit le projet d'arrêt correspondant, puis celui-ci est modifié et corrigé par les membres de la chambre qui s'expriment dans le même ordre que précédemment.

II La technique de cassation

Mais pour pouvoir remplir de front ces deux fonctions, l'harmonisation de l'interprétation de la loi et le contrôle de la légalité des jugements, la Cour de cassation doit pouvoir s'appuyer sur une technique précise et rigoureuse qui la conduise à ne saisir que des moyens qui la conduisent à contrôler l'application du droit par le juge. Ainsi centrée sur sa mission essentielle, la Cour évite de dépenser en vain son activité, les deniers des contribuables et le temps des justiciables à l'examen de moyens de fait qui ne relèvent pas de ses attributions.

1°/ Le pourvoi en cassation

Il convient d'abord de préciser que si le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'égard de décisions rendues en dernier ressort, (art. 605 du code de procédure civile), pour autant, toutes les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles de pourvoi. De façon générale, et sauf cas prévu par la loi, peuvent être seuls frappés de pourvoi les jugements rendus en dernier ressort et qui tranchent, en partie ou la totalité du principal.

Ne peuvent donc être frappés de pourvoi :

- les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance. Par exemple :
 - o les jugements qui prescrivent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal,
 - o les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir
 - o les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction (art. 150 et 808 CPC).

En revanche, peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation en vertu d'un texte spécial :

- o les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire (art 606)
- o les jugements, qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance (art. 607).

Ne peuvent non plus faire l'objet de pourvoi, par détermination de la loi ou de la jurisprudence :

- les mesures d'administration judiciaire (art. 537 du CPC)

- certaines mesures en matière de procédure collective
- les arrêts de la Cour de cassation (2eme civ 24 juin 1998, bull n° 207)
- la décision du premier président d'une cour d'appel autorisant l'appel contre un jugement ordonnant une expertise (2eme civ 26 février 1977, bull civ n° 58)
- les décisions dépourvues de caractère juridictionnel comme, par exemple, un jugement d'adjudication (2eme civ 5 juin 1996, bull civ n° 124)

La Cour de cassation est saisie par un pourvoi, déclaration formée dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, au greffe de la Cour de cassation, et, en matière civile, par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.

Le pourvoi peut être formé à titre principal, incident ou provoqué.

Le pourvoi incident est celui relevé par le défendeur avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour la remise d'un mémoire en réponse (deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif).

Le pourvoi provoqué est celui qui est formé dans l'hypothèse où une cassation interviendrait sur le pourvoi principal.

Le demandeur a ensuite quatre (depuis le décret du 22 Mai 2008) mois pour déposer un mémoire ampliatif dans lequel il doit formuler les critiques qu'il adresse à la décision attaquée, sous forme de "moyen de cassation". Ce dernier doit en quelques lignes exposer de manière concise et complète les critiques adressée à la décision attaquée.

L'importance du moyen est capitale car la cour n'est tenue de statuer que sur son contenu. Un moyen de pourvoi ne doit, sous peine d'irrecevabilité (du moyen), invoquer qu'un seul cas d'ouverture à cassation.

2° Les cas d'ouvertures à cassation

La Cour de cassation exerce un double contrôle. Tout d'abord, un contrôle normatif, qui vise à s'assurer de la légalité des décisions et l'interprétation de la loi par les juges du fond, ensuite, aussi un contrôle de rationalité qui porte non pas sur le sens du jugement mais sur la qualité de sa motivation.

Aussi, peut-on classer en deux catégories les différents cas d'ouverture à cassation dégagés par la pratique :

- ceux qui sanctionnent une erreur de droit et qui conduisent la Cour de cassation à contrôler la légalité de la décision.
- ceux qui sanctionnent des vices de motivation et qui conduisent la Cour de cassation à contrôler la rationalité de la décision.

a) Les erreurs de droit ou la violation de la loi

La cassation pour violation de la loi est la voie royale du pourvoi en cassation. C'est celle qui a la plus grande portée jurisprudentielle.

La violation de la loi conduit la Cour à vérifier la correcte application des textes par les juges du fond aux situations de fait qui leur sont soumises. Elle peut se manifester soit par un refus d'application, lorsque le juge du fond a refusé d'appliquer une loi à une situation de fait qu'elle devait régir, soit par

une fausse application, lorsque le juge a appliqué un texte à une situation de fait qu'il ne devait pas régir.

Il se peut ainsi que le juge a :

- ajouté au texte une condition qu'il ne pose pas (par ex : Civ 1ère, 27 janvier 1993, arrêt n° 2, bull n° 41)
- méconnu le champ d'application ou les conditions d'application d'un texte (par ex 3ème civ 8 juin 1988, bull n° 107, 12 juillet 1988, bull n° 123, 1ère civ 13 mai 1981, bull n° 165)
- commis une mauvaise qualification des faits. (Par ex : 2ème civ 30 janvier 1991, bull n° 42)

L'opération intellectuelle consistant à juger comporte trois étapes :

- l'appréciation des faits, laquelle échappe au contrôle de légalité de la Cour de cassation. Elle est donc exercée souverainement par le juge du fond qui doit seulement motiver sa décision, (Civ 2, 5 mars 2009, pourvoi 06-20 994). Toutefois le respect des règles de preuve de ces faits, et notamment de la charge de la preuve, est contrôlé car il s'agit d'une question de droit (Civ 1, 3 décembre 2008, pourvoi 08-10 718).

- La qualification des faits qui consiste à faire entrer les faits dans une catégorie juridique. Elle est en principe contrôlée. C'est ainsi, par exemple, que la Cour de cassation affirme, au sujet du contrôle de la faute délictuelle que « si les tribunaux constatent souverainement les faits, il appartient à la Cour de cassation d'apprécier si ceux-ci présentent les caractères juridiques de la faute prévue par la loi et engagent la responsabilité de leur auteur » (Cass. 2ème civ., 3 novembre 1955, D. 1955, p. 78 ; Cass. 2ème civ., 6 janvier 2000, no 97-21456 : Bull. 2000, II, no 4).

Cependant, certaines qualifications sont si imprégnées de fait qu'elle ne peut être contrôlée par la Cour de cassation faute de pouvoir dégager des critères généraux et abstraits qui permettraient de guider les juges du fond dans leur mission. C'est le cas, par exemple de la faute en matière de divorce ou de la bonne foi en matière de surendettement. Le trouble manifestement illicite, en matière de référé, fait au contraire, l'objet d'un contrôle léger à la suite d'un arrêt d'assemblée plénière du 28 juin 1996 (Bull. AP n° 6) qui est revenu sur les décisions de l'assemblée plénière du 4 juillet 1986 (Bull AP 11) et celles postérieures de la deuxième chambre civile qui privilégiaient la notion de trouble (question de pur fait) sur le "manifestement illicite" (question de droit mais qui doit être évidente 25 octobre 1995 Bull 255).

- Les conséquences juridiques de la qualification des faits retenus sont toujours contrôlées.

Ce contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation peut être de deux niveaux :

- **le contrôle léger** : C'est un contrôle de légalité qui intervient lorsque la cour d'appel a tiré une conséquence juridique de ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être différente sans pour autant encourir la critique et ce contrôle léger s'exprime par une réponse au rejet selon laquelle le juge du fond "a pu....." statuer comme il l'a fait : (Com. 17 février 2009 pourvoi 07-20.458) *"que la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement était fautif et devait entraîner pour M. D. décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par voie de subrogation ; que le moyen n'est pas fondé"*.

- **le contrôle lourd** : Il intervient lorsque la cour d'appel ne pouvait, à partir de ses constatations de fait, qu'aboutir à la solution retenue sous peine de voir son arrêt cassé pour violation de la loi : **les arrêts de rejet utilisent alors des expressions très fortes telles que "exactement", "à bon droit"** lorsque le juge a énoncé pertinemment une règle (Civ.2 19 février 2009 pourvoi 08-11.888) : *" Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni*

les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable". Le mot "justement" est utilisé de préférence lorsque le juge a correctement tiré les conséquences d'un texte (Civ 1, 11 février 2009, pourvoi 07-16.993).

Il est en revanche deux domaines dans lesquels la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle de légalité :

- Le pouvoir discrétionnaire est un pouvoir que le juge peut exercer sans être tenu de motiver sa décision: par exemple en application de l'article 1244-1 code civil pour refuser d'accorder des délais de paiement, pour refuser de modérer une clause pénale (1152 du code civil), pour refuser une demande de sursis à statuer, pour fixer la charge des dépens ou le montant des frais non compris dans les dépens (art. 700 du cpc), ou ordonner l'exécution provisoire. Il échappe ainsi à tout contrôle de la part de la Cour de cassation, que ce soit un contrôle de légalité ou de rationalité. Dans ces cas les arrêts de la Cour de cassation mentionnent que le juge n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire (Com 16 septembre 2008, pourvois 07 11 803 et 07-12.160,, Civ 1, 11 février 2009 pourvoi 08 11 337).

- Le pouvoir souverain est un pouvoir que le juge peut exercer à condition de motiver sa décision. En revanche, la pertinence de cette motivation échappe au contrôle de la Cour de cassation qui se borne à vérifier son existence. (Civ 2 19 février 2009, pourvoi 07-19.340) *"...c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que son attitude était constitutive d'un abus de droit"*. Il échappe donc au contrôle de légalité, mais non à celui de rationalité.

b) Les erreurs de motivation

Les moyens qui invitent la Cour à exercer ce contrôle, qualifiés souvent de « disciplinaires », critiquent la façon dont la décision a été rédigée, et non pas, du moins directement, la solution adoptée.

Parmi les cas d'ouverture les plus souvent invoqués figure le **manque de base légale** qui correspond à une insuffisance de la décision au fond quant à l'énonciation des faits, lorsque celle-ci ne donne pas les éléments suffisants pour permettre à la Cour de cassation, qui ne peut entreprendre aucune investigation sur les faits, de dire si la loi a été ou non correctement appliquée. Cette cassation peut donc très bien être suivie d'une seconde décision au fond, adoptant, sur renvoi, la même solution que la décision cassée. Il suffit à la juridiction de renvoi d'évoquer dans sa décision les précisions de fait qui manquaient à la décision cassée pour défaut de base légale.

Le manque de base légale peut résulter:

- de l'incertitude quant au fondement juridique de la décision (par ex 1ere ch 4 mars 1962, bull n° 161)
- de l'absence de constatation d'une condition d'application de la loi, que cette qualification soit ou non contrôlée. par ex : 1^{ère} civ 26 janvier 1983, bull n° 40 pour une qualification non contrôlée, ou 2^{ème} civ 2 avril 1979, bull n° 109 pour une qualification contrôlée, 17 janvier 1985, bull n° 15)
- de l'insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l'application de la loi, que cette recherche soit obligatoire (par ex : 2^{ème} civ, 7 décembre 1983, bull n° 193) ou facultative mais demandée par une partie (com 10 juin 1986, bull n° 118)

La Cour de cassation indique alors *« qu'en statuant ainsi, en l'état de ses constatations ou sans rechercher, sans préciser, sans s'expliquer, sans constater (tel fait), (éventuellement : ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »*

En revanche, s'il s'agit d'un rejet « *qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision* »

Les moyens disciplinaires

On appelle moyens disciplinaires ceux qui, en se prévalant de la violation d'une règle de droit, n'ont d'autre but que de faire censurer la décision attaquée pour la façon dont elle a été rédigée, et non pas, du moins directement, en raison de la solution adoptée.

- Le défaut de réponse à conclusions. Ici, on reproche au juge du fond de ne pas avoir répondu aux moyens des parties. C'est un cas d'ouverture fréquemment utilisé mais dont la Cour de cassation réduit les possibilités. Pour faire simple, elle considère que les juridictions n'ont à répondre qu'aux moyens (et non aux arguments) opérants, c'est à dire qui étaient de nature à entraîner une autre solution que celle adoptée. La cour de cassation peut également considérer, pour rejeter le moyen, que les juges du fond ont implicitement ou nécessairement répondu aux conclusions en faisant telle ou telle constatation, ou encore suppléer l'absence de réponse par un motif de pur droit qu'elle énonce elle-même (par ex : 1ère civ, 25 mai 1982, bull n° 187)

- Les vices de motifs. Ici, on s'attaque à l'explication donnée par le juge. Les décisions de justice devant être motivées y compris lorsque le juge du fond se voit reconnaître par la Cour un pouvoir souverain d'appréciation (Seul le pouvoir discrétionnaire dispense le juge de l'obligation de motiver sa décision) l'absence de motivation constitue une violation de l'article 455 du CPC. On peut reprocher à sa décision de comporter une insuffisance de motifs, une contrariété de motifs ou des motifs dubitatifs.

Par exemple : pour un défaut de motif : 2ème civ, 4 février 1987, bull n° 34, un motif d'ordre général : 1ère civ, 2 novembre 1981, bull n° 362, un motif dubitatif : 2ème civ, 6 décembre 1995, bull n° 302

- La dénaturation d'un acte clair. Dénaturer un document, c'est lui donner un sens qu'il n'a pas. En principe, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur l'interprétation que fait un juge du fond d'un document (il s'agit d'une question de fait), sauf dans l'hypothèse où cette interprétation équivaut à une véritable dénaturation d'un acte clair.

2° La forme des arrêts

Comme il a déjà été indiqué, dans un souci de clarté, les arrêts de la Cour de cassation sont rédigés non pas comme les jugements des juridictions ordinaires, qui doivent justifier leur décision, mais de façon concise, comme des textes de loi, et énoncent de façon nette et précise la règle qu'ils fixent. Le même souci a conduit depuis la création du Tribunal de cassation en 1790 les magistrats à mettre au point une rédaction normalisée.

Rédigé dans un style normalisé, dépourvu de considérations personnelles ou d'opinions dissidentes, l'arrêt de la Cour de cassation apparaît comme le produit d'une institution, d'une entité, et non comme le jugement d'un ou plusieurs individus. Il engage toute la Cour de cassation, et non les seuls magistrats qui l'ont délibéré ou son rapporteur. Cette conception collective de la décision de justice, qui s'oppose à l'approche individualiste des pays de Common Law, dans lesquels la décision de justice est d'abord celle de tel ou tel juge, reflète le souci d'impartialité du jugement et d'unicité dans l'application de la loi qui caractérise l'état d'esprit de la Cour de cassation.

Cette différence entre les deux systèmes résulte des visions opposées du juge et de l'organisation judiciaire. Le système de Common Law fait une large part à la personnalisation du juge. Nommé le plus souvent à l'issue d'une carrière au barreau, il jouit d'un prestige qui lui confère une autorité

personnelle suffisante sans avoir besoin d'être légitimé par une structure hiérarchisée. Dans le système continental, en particulier en France, le juge est le produit d'un groupe. Il n'exerce pas ses fonctions de façon individuelle, mais au contraire inséré dans une structure dont la cohérence est assurée par son caractère hiérarchisé et la normalisation de ses pratiques.

Comme toute décision judiciaire, un arrêt de la Cour de cassation correspond à la formalisation du raisonnement de la Cour qui, partant de circonstances de fait souverainement retenues par les juges du fond, est saisie d'une contestation de la décision des juges du fond au moyen d'un argumentaire juridique. Si elle approuve le raisonnement des juges, la Cour rejette le pourvoi. Si elle le réfute, elle casse la décision attaquée. Mais, contrairement à ce qu'elle exige des juges du fond, la Cour de cassation, juge du droit, n'exprime pas la motivation de sa décision en ce sens qu'elle "dit le droit" sans dire pourquoi elle privilégie telle ou telle interprétation de la loi.

Comme les décisions des juges du fond, l'examen des moyens s'opère dans un ordre logique (recevabilité avant le fond, principe de responsabilité avant l'indemnisation du préjudice qui est nécessairement préalable à l'examen des moyens portant sur les appels en garantie etc.). Dès lors qu'un de ces moyens est accueilli, l'examen des moyens qui, en pure logique, ne portent que sur une conséquence du chef de dispositif cassé, n'a pas lieu. Cette situation s'exprimera par l'indication juste avant le dispositif de la formule: "*Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ...*".

Un arrêt de rejet comporte généralement, avant son dispositif, trois parties :

- un exposé sommaire des faits et de la procédure (« *Attendu, selon l'arrêt attaqué, que ...* »). Il ne comprend que les éléments factuels strictement nécessaires à la compréhension du moyen et de sa réfutation par la Cour.
- l'exposé du ou des moyens de cassation formulés dans le mémoire en demande (« *Attendu que X fait grief à l'arrêt d'avoir...* »), précédé du chef de dispositif attaqué.
- la réfutation de ce ou de ces moyens (« *Mais attendu que... D'où il suit que le moyen n'est pas fondé (ou ne peut être accueilli)*). En général, la réfutation résulte de l'approbation par la Cour de cassation de la motivation des juges du fond « *qu'ayant retenu que ..., la cour d'appel en a exactement déduit que* », si une violation de la loi est invoquée, ou « *qu'ayant relevé que ..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision* » pour un manque de base légale. Si la motivation des juges du fond n'est pas pertinente, la Cour de cassation peut réfuter le moyen en substituant d'office au motif un motif qui lui est propre, à condition toutefois qu'il s'agisse d'un motif de pur droit, c'est-à-dire un motif qui ne la conduirait pas à procéder elle-même à une recherche ou une appréciation factuelle.

La réfutation peut concerner un ou plusieurs moyens, dans la même phrase ou dans plusieurs paragraphes.

Si la Cour de cassation entend énoncer une règle générale, elle fait débiter sa réponse par une formulation abstraite appelée "un chapeau intérieur". Ce chapeau est suivi immédiatement de la constatation que la décision attaquée a fait une correcte application du principe ainsi énoncé.

L'arrêt de cassation suit toujours le même plan :

- d'abord, le visa de *la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée* (art. 1020 du code de procédure civile), en général un texte de loi ou de décret, parfois un principe général du droit. Il s'agit du texte qui aurait dû être appliqué s'il s'agit d'une cassation pour refus d'application, ou de celui qui a été appliqué à tort si la cassation intervient pour fausse application.

- l'énoncé de la règle de droit qui a été violée, en principe la reproduction, parfois leur synthèse, du texte ou du principe visé, ou, lorsque plusieurs textes sont visés la règle résultant de leur combinaison. En cas de cassation pour manque de base légale, l'arrêt ne comporte pas généralement de chapeau après le visa. Lorsque le texte est très connu, la Cour de cassation se dispense d'en rappeler la règle dans le chapeau (par ex. art. 1382 c. civ.).

- ensuite, s'il est nécessaire pour la compréhension de l'arrêt, l'exposé sommaire des faits et de la procédure ;

- puis ce qu'à décidé la décision attaquée, ou la partie de cette décision critiquée par le moyen, avec le rappel des motifs que la juridiction a retenus pour la justifier ;

- enfin, le conclusif, qui énonce en quoi la juridiction a ainsi violé la règle de droit mentionnée dans le chapeau (cassation pour violation de la loi), ou, par une motivation insuffisante, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si cette règle a été ou non correctement appliquée (cassation pour manque de base légale). Ce conclusif peut comporter un « chapeau intérieur » qui contient l'interprétation que la Cour fait du texte visé ou les conséquences juridiques qu'elle tire au cas d'espèce (précédé de la formule « *alors que ...* »)

- le dispositif de l'arrêt, après le « par ces motifs », qui prononce la cassation qui peut être totale, partielle, avec ou sans renvoi.

La juridiction qui reçoit le renvoi est théoriquement totalement libre d'apprécier l'affaire qui lui est renvoyée. Elle peut constater et rechercher des faits nouveaux, analyser différemment les faits déjà appréciés. Elle peut statuer dans le même sens que la première juridiction, ou adopter le point de vue de la Cour de cassation ou encore adopter une solution nouvelle.

Si le nouvel arrêt après renvoi ne donne pas satisfaction à l'une des parties, un nouveau pourvoi en cassation peut être formé. Si le pourvoi est formé sur les mêmes moyens que lors de la première cassation, la Cour de cassation doit alors se prononcer en Assemblée plénière.

Elle peut valider le second arrêt déféré ou rejeter le second pourvoi et renvoyer devant une troisième juridiction du fond de même nature et de même degré. Celle-ci garde la maîtrise de l'appréciation des faits et des points de droit non soumis à la Cour de cassation. En revanche elle doit obligatoirement se soumettre à l'appréciation de validité qui a été faite par la Cour de cassation.